

1500087-87.2022.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

E é certo que a perscrutação da intenção do agente ao praticar determinada conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500087-87.2022.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500087-87.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068369/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 23543454 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2068369 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA SANTOS FELICISSIMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de JESSICA SANTOS FELICISSIMO, já qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, a acusada, no dia 11 de março de 2022, às 10h15, na Rua Frutuoso de Melo Pimentel, nº 93, Vila Santa Maria, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, teria em depósito e guardava, para fins de tráfico, 14 (quatorze) porções de maconha, com peso líquido de 26,20g (vinte e seis gramas e vinte centigramas), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 109/111). A ré foi notificada (fls. 125), apresentou

sua defesa preliminar (fls. 122/123) e a denúncia foi recebida (fls. 126/128). Em audiência, foram ouvidas três testemunhas, bem como a ré foi interrogada. As partes apresentaram alegações finais em audiência.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

De início, rejeita-se a impugnação realizada pelo patrono da acusada, no sentido de que o Magistrado, ao iniciar as perguntas à testemunha, estaria violando o sistema acusatório e/ou induzindo o depoente.

Adota-se o entendimento de que o artigo 212 do CPP não retirou do juiz a possibilidade de dar início às perguntas em audiência, antes das indagações das partes. O artigo em comento apenas eliminou a necessidade de que as perguntas formuladas pelas partes passassem pelo juiz para que este as endereçasse às testemunhas.

Ainda, Segundo o escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, essa inovação "não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes se dizia-se que" as perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha ", agora se diz que" as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...).".

Nota-se, pois, que absolutamente nenhuma modificação foi introduzida no tradicional método de inquirição, iniciado sempre pelo magistrado. E quanto às perguntas das partes (denominadas reperguntas na prática forense), em lugar de passarem pela intermediação do juiz, serão dirigidas diretamente às testemunhas. Depois que o magistrado esgota suas indagações, passa a palavra à parte que arrolou a pessoa depoente [...]

Ao término, como sempre se fez, o magistrado pode refazer alguma pergunta, extrair qualquer dúvida sua e solicitar esclarecimentos complementares à testemunha (art. 212, parágrafo único, CPP). Aliás, mesmo antes da existência do referido parágrafo único, o juiz jamais deixou de atuar desse modo. Desnecessária foi a inclusão no art. 212" (Provas no Processo Penal, Forense, 4a ed., p.226)."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CP. INTERNAÇÃO. ART. 212 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM EVIDENCIADAS. 1. Sentença que julgou procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação. Irresignação da Defesa. 2. Prova testemunhal que se destina unicamente à formação do convencimento judicial acerca dos fatos descritos na representação. Artigo 212 do CPP que apenas eliminou o sistema anterior de inquirição das testemunhas, que previa que todas as reperguntas formuladas pelas partes passassem pelo juiz para que este as endereçasse às testemunhas. Não adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do sistema acusatório puro. Magistrado não está impedido de formular indagações às testemunhas antes da formalização de perguntas pelas partes. Entendimento diverso demandaria comprovação de efetivo prejuízo, consoante entendimento das Cortes Superiores, não evidenciado nos autos. Inexistência de qualquer mácula nas perguntas formuladas pela magistrada às testemunhas. Nulidade não configurada. 3. Prova oral aliada aos elementos de convicção amealhados nos autos, sobretudo, a concatenação cronológica dos fatos que precederam o ato infracional, que são mais do que suficientes para a procedência da representação. 4. Recurso desprovido". (TJ-SP - AC: 15002239120218260631 SP 1500223-91.2021.8.26.0631, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 22/02/2022)

E não discrepa desse posicionamento, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao ressaltar que o magistrado não está impedido de formular indagações às testemunhas antes da formalização de perguntas pelas partes (STF, HC nº 105.538, Rel. Min. Marco Aurélio).

Por fim, fosse proibida a iniciativa probatória ao Magistrado, não haveria a possibilidade de produção antecipada de provas ex officio, tal como dispõe o artigo 156, do CPP.

Superada a questão preliminar, analiso o mérito.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal da ré, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto preliminar de constatação (fls. 12/14), pelo laudo definitivo (fls. 93/96), pelo relatório de investigação (fls. 98/99), e pela prova oral coligida. A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O policial militar Danilo Campolim de Almeida, em juízo, disse que receberam informações de que uma mulher chamada Jéssica estaria comercializando entorpecentes no citado endereço. Diante disso, afirmou que realizaram buscas no sistema de dados, bem como ficaram de campana no endereço informado. Afirmou que o bairro já era conhecido como ponto de venda de drogas. Esclareceu que, durante a campana, conseguiram constatar movimentação característica do tráfico de drogas. Assim, relatou que foi representado por busca e apreensão no local, que foi deferida judicialmente. Declarou que, no dia dos fatos, foram cumprir o mandado de busca, com apoio da guarda municipal. Disse que a ré e o namorado dela estavam no local. Afirmou que a cachorra da guarda municipal indicou uma fresta que havia no local, onde localizaram as porções de drogas. Relatou que, continuando as buscas no interior da residência, encontraram certa quantia em dinheiro e um caderno de anotações, o qual, explicitamente, citavam quantidades de entorpecentes e suas pesagens. Afirmou que a acusada admitiu a propriedade da droga, mas disse que era para seu consumo. Esclareceu que o mandado de busca foi expedido em nome de outra Jéssica, mas que, chegando no local, encontraram a ré, que também chamava Jéssica, mas que tinha outra qualificação. Confirmou que houve um equívoco na qualificação da investigada. Relatou que as investigações também envolvia uma pessoa chamada Débora e que, ao indagarem a acusada, no momento da abordagem, ela disse que conhecia uma Débora, mas não entrou em detalhes. Confirmou que tinham crianças no local e que eram filhos da ré. Esclareceu que a acusada ficou sentada enquanto a cachorra farejadora realizava buscas no local. Por fim, relatou que o local da abordagem fica próximo a uma escola.

A guarda municipal Adriano Mateus Gnoatto Simão, ouvida em juízo, disse que, no dia dos fatos, foi dar apoio ao cumprimento de mandado de busca na residência da acusada. Afirmou que o cão ficou entre uma parede e um muro que tinha no local, oportunidade em que encontraram as porções de drogas. Confirmou que foi encontrada certa quantidade em dinheiro no local – cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, confirmou que foi encontrada uma anotação referente ao tráfico no local. Relatou que a ré disse que as drogas eram para uso. Afirmou que a acusada estava ciente das buscas realizadas na residência e que estava no local. Disse que não chegou a conferir os dados no mandado de busca e apreensão.

A informante Kátia Santos Felicíssimo, em juízo, relatou que é irmã da acusada. Afirmou que estava na casa de sua irmã no momento em que os policiais chegaram no local, para cumprimento do mandado de buscas. Disse que não viu o momento em que os agentes encontraram as drogas. Relatou que, na casa, estavam ela, sua irmã e os filhos de Jéssica. Confirmou que ela e sua irmã são usuárias de drogas. Declarou que a acusada vende roupas e faz prendedores de roupas. Esclareceu que deixavam as drogas na parte de fora da casa, em razão das crianças, bem como para que outros usuários não pedissem as drogas. Relatou que sua irmã morava na residência há cerca de três meses e que a antiga moradora também chamava-se Jéssica. Afirmou que a quantidade de drogas apreendidas duraria aproximadamente uma semana, pois ambas usavam os entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, a ré disse que morava no endereço em que houve cumprimento da ordem e busca e apreensão havia três meses. Afirmou que antes, morava na Rua Dez, Vila Santa Maria. Esclareceu que mudou de residência, pois seu ex-marido lhe perturbava. Afirmou que trocou de casa e que em seu atual endereço morava uma pessoa chamada Débora, que possui uma cunhada que também tem o nome de Jéssica – Jéssica Proença. Confirmou as propriedades das drogas, mas disse que era

para seu uso. Declarou que escondia os entorpecentes, em razão de seus filhos. Afirmou que as anotações encontradas eram referentes às anotações de suas vendas. Disse que sua filha achou uma folha de anotações na Rua, mas que não tinham relação com suas anotações e que não estava em seu caderno.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

E é certo que a perscrutação da intenção do agente ao praticar determinada conduta constitui uma das tarefas mais árduas no âmbito da análise da adequação normativo-típica da ação do agente criminoso, notadamente porque se trata de aspecto interior, impassível de averiguação científica.

É por isso que abalizada doutrina aponta para a necessidade de avaliação das circunstâncias do caso concreto para que se chegue a um juízo a respeito do dolo do agente. Nesse sentido:

“Em relação especificamente a prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposos.

Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios, ou seja, circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, a evidencia, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias (art. 239).” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 17ª Ed., 2014, p. 333/334)

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No presente caso, os policiais relataram que as investigações se iniciaram após o recebimento de informações anônimas, indicando a comercialização de entorpecentes no local. Após constatarem movimentação característica de tráfico de drogas no endereço informado, elaboraram relatório e representaram por busca e apreensão no local, o que foi deferido judicialmente (autos nº 1500232-35.2022.8.26.0270). No dia dos fatos, os policiais civis, com apoio da guarda municipal, foram realizar o cumprimento do mandado de busca e, chegando na residência, estavam no local a ré, sua irmã e seu namorado. Esclareceram que, iniciadas as buscas, a cadela Zara indicou um vão entre uma parede lateral e o muro, onde foram encontradas as 14 (quatorze) porções de maconha. Além disso, no interior da casa, foi localizado um papel manuscrito, que continha anotações de tráfico de drogas, um celular, e a quantia de R\$1.168,50 (mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

Note-se que os agentes civis prestaram narrativas coerentes e uníssonas, contando com detalhes os fatos ocorridos, não existindo, no presente processo, nenhum indicativo de que tenham a intenção de incriminar a ré injustamente.

O testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. O simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais não conduz a que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e

objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

A ré, por sua vez, negou o crime, dizendo ser usuária de drogas. No entanto, não trouxe ao feito nenhuma prova que corroborasse sua alegação.

Frise-se que, embora não se possa descartar a hipótese de que a ré também seja usuário de drogas, a quantidade de droga apreendida, o fato de os entorpecentes estarem escondidos entre a parede e o muro, bem como de ter sido encontrado no local anotações de contabilidade de venda de drogas, torna impossível considerar que os entorpecentes destinavam-se apenas ao uso próprio.

Por fim, ao contrário do que alega a defesa, não há dúvidas de que a acusada seja o alvo da representação pela expedição do mandado de busca que culminou no encontro das drogas e na sua prisão.

A divergência de qualificação foi esclarecida pelo policial Danilo Campolim, o qual asseverou que o mandado de busca foi expedido em nome de outra Jéssica, mas que, chegando no local, encontraram a ré, que também chamava Jéssica, mas que tinha outra qualificação. Confirmou que houve um equívoco na qualificação da investigada. Ora, não se pode exigir que em todos os casos, os agentes policiais detenham a qualificação completa do alvo do mandado de busca, não sendo raras as hipóteses em que sequer sabem o primeiro nome da pessoa, contudo, há certeza quanto ao local das supostas infrações.

As investigações apontavam que o tráfico era exercido naquele endereço, e que a autora se chamaria Jessica, sendo expedido o mandado de busca domiciliar. Nesta situação, o ingresso no domicílio precedeu de ordem legal, também para obter a qualificação correta da agente que em tese praticava no local a comercialização de entorpecente.

Assim, se a medida foi precedida de investigações, e se foram apreendidos os itens que demonstravam realmente a prática delitiva naquele local, não há motivo para se reconhecer qualquer nulidade apenas à conta da imprecisão na qualificação completa da moradora, que, como visto, detinha o prenome correto.

Fato é que a ré, conforme a prova dos autos, detinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, quatorze porções do entorpecente conhecido como “maconha”, com peso líquido de 26,20g.

O crime em tela é de consumação permanente, sendo possível a prisão em flagrante a qualquer momento, inclusive prescindindo de mandado de busca domiciliar, haja vista a exceção à inviolabilidade do domicílio estampada no artigo 5º, inciso XI, da CF.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

Por fim, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve incidir.

É que restou incontroverso nos autos que o tráfico ocorreu nas imediações de uma escola, conforme relatos dos policiais, bem como relatório de investigações de fls. 98/99.

Desta forma, deve haver a incidência da majorante.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar as penas.

DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que a ré não possui anotações que caracterizem Maus antecedentes (cfe. documentos de fls. 32/34).

Por outro lado, nota-se que as circunstâncias do crime dão desfavoráveis, posto que praticava o delito na presença de crianças, in casu, seus filhos, conforme ela

própria narrou em interrogatório judicial. Os demais elementos são neutros. Assim, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, uma vez que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

Desse modo, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Entendo não ser possível o reconhecimento do privilegio do artigo 33,§4º, da lei de drogas, vez que, conforme denuncia formulada à Polícia Civil e em campanhas por esta realizada, foi constatado movimentação característica do tráfico de drogas que, inclusive, motivou a representação pela expedição de mandado de busca no local.

A minorante em comento deve ser aplicada a hipóteses específicas em que se verifica que o fato foi um episódio isolado da vida do agente, e não àqueles que fazem do comércio espúrio seu meio de vida e, a par da ausência de registros pretéritos, reiteram em sua empreitada, conforme comprovado nos autos.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, bem como a circunstancia judicial negativa, entendo que a pena imposta à ré deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razão do quantum da reprimenda aplicada, indevidas a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré JESSICA SANTOS FELICISSIMO a cumprir pena privativa de liberdade correspondente 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Decreto a perda da quantia apreendida em favor da União, conforme art. 63, §1º, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Custas pela acusada.

Oportunamente, intime-se a ré para o pagamento da sanção pecuniária, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia para início da execução, bem como certidão de honorários, se for o caso.

P.I.C.

Itapeva, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA